

《【문제2】 취소심판의 재결이 내려지기 전에 청구인이 제기할 수 있는 행정심판법상의 잠정적인 권리구제수단에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 취소심판의 재결이 내려지기 전 청구인이 제기할 수 있는 행정심판법상 잠정적 권리구제수단

I. 문제 제기

- 행정심판은 원칙적으로 본안재결을 통하여 권리구제가 이루어진다. 그러나 본안재결이 있기까지 상당한 기간이 소요되며, 그 사이 처분의 집행으로 인해 청구인에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 수 있다. 따라서 행정심판법은 청구인의 권리를 잠정적으로 보호하기 위하여 집행정지와 임시처분이라는 제도를 두고 있다. 이하에서는 이들 제도의 의의와 요건 및 한계에 대하여 설명한다.

II. 집행정지

1. 의의

- 집행정지란 행정심판의 계속 중 처분 또는 그 집행이나 절차의 효력을 일시적으로 정지시켜, 본안재결 전까지 청구인의 권리를 잠정적으로 보호하는 제도를 말한다. 이는 소극적 권리구제수단으로서 처분의 효력 자체를 정지시키는 기능을 가진다.

2. 요건

(1) 본안 청구의 적법성

- 본안인 취소심판 청구가 적법하게 제기되어 있어야 한다.

(2) 회복하기 어려운 손해 발생 우려

- 처분의 집행으로 회복하기 어려운 손해가 발생할 가능성이 있어야 한다. 단순한 불편이나 경미한 손해는 부족하다.

(3) 긴급한 필요성

- 손해 발생이 급박하여 본안재결까지 기다릴 수 없는 필요성이 인정되어야 한다.

(4) 공공복리에 중대한 영향 없음

- 집행정지를 허용할 경우 공익에 중대한 해가 발생하지 않아야 한다.

(5) 본안 청구가 이유 없음이 명백하지 않을 것

- 본안에서 전혀 인용 가능성이 없는 경우에는 집행정지가 허용되지 않는다.

3. 한계

- 집행정지는 처분의 효력을 정지시키는 데 그치므로 적극적으로 청구인의 권리를 실현시키는 데에는 한계가 있다. 또한 공익적 고려가 우선되는 경우에는 인용되지 않는다.

III. 임시처분

1. 의의

- 임시처분은 집행정지로는 충분한 구제가 불가능한 경우에, 청구인의 권리 또는 법률상 이익을 실효적으로 보전하기 위하여 행정심판위원회가 잠정적으로 일정한 행위를 명하거나 금지하는 적극적 권리구제수단이다.

2. 요건

(1) 본안 청구의 적법성

- 본안심판 청구가 적법하여야 한다.

(2) 중대한 불이익 또는 급박한 위험 발생 우려

- 임시처분을 하지 않으면 청구인에게 중대한 불이익이나 급박한 위험이 발생할 우려가 있어야 한다.

(3) 집행정지로는 목적 달성 곤란

- 단순한 효력정지만으로는 권리보호가 충분하지 않은 경우여야 한다.

(4) 공공복리에 중대한 영향 없음

- 공익을 심각하게 해하지 않아야 한다.

(5) 본안 청구가 이유 없음이 명백하지 않을 것

- 본안에서 인용 가능성이 전혀 없는 경우에는 임시처분을 허용하지 않는다.

3. 특징

(1) 적극적 구제 가능

- 집행정지가 소극적 권리구제라면, 임시처분은 행위의 정지, 행위의 명령 등 적극적인 조치를 명할 수 있다.

(2) 보충성

- 집행정지로는 목적을 달성할 수 없는 경우에 한해 보충적으로 인정된다.

IV. 결론

- 행정심판법은 청구인의 권리보호를 위하여 본안재결 전에도 잠정적인 권리구제수단을 인정한다. 집행정지는 처분의 효력이나 집행을 정지시켜 본안재결 전 회복하기 어려운 손해를 예방하는 소극적 권리구제수단이다. 임시처분은 집행정지로는 부족한 경우 청구인의 권리 실현을 위하여 적극적인 행위를 명할 수 있는 보충적 권리구제수단이다. 따라서 본안재결 전에도 청구인은 이들 제도를 통하여 권리 보호를 잠정적으로 확보할 수 있다.